

1501041-89.2021.8.26.0648

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VINICIUS NUNES ABBUD

Comarca: Urupês

Foro: Foro de Urupês

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 29/07/2022

... pelos tribunais pátrios:

"Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2o, da Lei nº 11.343/06, 'contrario sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Urupês - Foro de Urupês - Vara Única

Praça Jardim Bela Vista, s/n, Urupes - SP - cep 15850-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501041-89.2021.8.26.0648 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501041-89.2021.8.26.0648

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADEMIR LUIZ PEREIRA JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VINICIUS NUNES ABBUD

Processo nº 1501041-89.2021.8.26.0648

Vistos.

ADEMIR LUIZ PEREIRA JUNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006, porque no dia 09 de dezembro de 2021, por volta das 11h20min, na Rua Domingos Gonçalves Pereira, 57, centro, no município e Comarca de Urupês, teria trazido consigo 06 porções de maconha, com peso bruto aproximado de 12 gramas, o fazendo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com intuito de fornecer ou entregar as substâncias ilícitas ao consumo de terceiros.

A denúncia teve por base o inquérito policial e, após defesa preliminar (fls. 117/121), foi recebida no dia 10 de fevereiro de 2022 (fl. 122).

Ao longo da instrução, foram ouvidas as testemunhas tempestivamente arroladas, seguindo-se o interrogatório do réu.

Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação, nos termos da denúncia, por considerar provadas autoria e materialidade. A defesa, por sua vez, pugnou pela aplicação ao caso da causa de diminuição de pena veiculada no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

Processo em ordem, que se desenvolveu em obediência aos princípios do contraditório

e da ampla defesa. Não há nulidade a ser declarada ou vício a ser sanado. Quanto ao mérito, iniciando as necessárias perquirições pela imputação referente à prática do tráfico, observo que a materialidade delitiva foi demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 07/08), auto de exibição e apreensão (fl. 11), laudo de constatação (fl. 13), laudo de exame químico toxicológico (fls. 107/109), bem como pela prova oral colhida.

A autoria é certa e indubitosa.

A testemunha Everton Willian Flores, policial militar, declarou que estava em patrulhamento quando avistaram dois indivíduos na via pública, os quais, ao avistarem a viatura, tentaram se separar e seguiram cada um para um lado da via. Ato contínuo se aproximaram e identificaram os indivíduos como sendo Ademir e Richard, ambos conhecidos nos meios policiais. Realizada a busca pessoal em ambos, no bolso de Ademir foram localizadas 06 porções de maconha, embaladas para venda e na carteira de Richard havia R\$ 1.900 em dinheiro. Indagados, Ademir alegou que estariam indo fumar a maconha, porém o Richard alegou que estaria indo comprar a droga de Ademir. Diante dos fatos foi dada a voz de prisão e ambos conduzidos ao Distrito Policial. Segundo os indivíduos, estavam a caminho da casa de Ademir. Informou que ambos eram conhecidos nos meios policiais em razão do envolvimento com drogas. Relatou que Richard estava com um companheiro que o esperava nas proximidades do local onde realizada a abordagem.

A testemunha Rogério Neres da Costa, policial militar, disse que estava em patrulhamento, acompanhado do cabo Wilian, quando se depararam com Ademir e Richard. Narrou que ao avistarem a viatura, os indivíduos seguiram em direções opostas, motivo pelo qual decidiram realizar a abordagem. Realizada a busca pessoal, com Ademir foram localizadas 06 porções de maconha e com Richard foi localizada a quantia de R\$ 1.920,00 em sua carteira. Indagados, Richard afirmou que Ademir havia lhe oferecido a maconha para vendê-la. Ademir, por sua vez, disse aos policiais que havia convidado Richard para consumirem a droga juntos. Contou que haviam denúncias, recebidas via disque-denúncias, indicando o envolvimento do réu com o tráfico de drogas.

Nesse quadro, na esteira de entendimento corrente, cumpre enfatizar que o depoimento de policial, autoridade investida de poder estatal, goza de inegável valia, tratando-se de prova apta a amparar a condenação, sobretudo no presente caso, em que não paira sobre as testemunhas, de forma fundada e concreta, qualquer suspeita de parcialidade ou inidoneidade.

Evidentemente, afigurar-se-ia injusto, e até ilógico, encarregar a polícia da segurança pública e depois desconsiderar os depoimentos que seus agentes venham a prestar, dando conta de suas perigosas e respeitáveis atividades funcionais.

Nesse sentido:

Tráfico de entorpecentes – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (...) (TJSP; Apelação Criminal 0094524-48.2014.8.26.0050; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 7ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/10/2016; Data de Registro: 01/11/2016);

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO LASTREADA EM VASTO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. IMPOSSIBILIDADE DE IMERSÃO VERTICAL NA MOLDURA FÁTICA E PROBATÓRIA DELINEADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM NA VIA PROCESSUAL ELEITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR NÃO DEFINITIVA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. MATÉRIA

PACIFICADA NO ERESP 1.431.091/SP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação no referido delito foi lastreada em vasto acervo probatório, sendo que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. A incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. A Terceira Seção pacificou entendimento no sentido de que é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (EResp 1.431.091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 1º/2/2017). (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

A testemunha Richard Renan Pereira afirmou que havia recebido o valor de R\$ 2.000,00 a título de verbas trabalhistas e estava junto com Carlos, seu companheiro. Disse que pararam no posto localizado na saída do município, oportunidade que o declarante foi até a loja de conveniência e seu companheiro seguiu para o supermercado. Relatou que encontrou o acusado, conversaram e seguiram até um local próximo para comprar entorpecente que seria imediatamente consumido, contudo, foram abordados no trajeto. Contou que os policiais encontraram a droga na posse do réu, porém o declarante não tinha conhecimento sobre a existência de tal entorpecente, pois o réu havia lhe falado que comprariam a droga de um terceiro indivíduo. Sustentou que ficou surpreso quando a droga foi encontrada. Esclareceu que seu companheiro ficaria lhe esperando enquanto iria comprar a droga, na companhia do Réu.

A testemunha Carlos César Sanches contou que trouxe Richard para receber o acerto, na fábrica do Sr. José Spadoto. Após saírem da fábrica, o declarante entrou no mercado Rede Sol para comprar alguns produtos e Richard falou que iria comprar um salgado. Ao sair do mercado, não encontrou Richard e, logo em seguida, avistou a viatura da polícia e os dois indivíduos já abordados. Disse que os policiais o indagaram se estava na companhia de Richard, o que foi confirmado pelo declarante. Após, os indivíduos foram conduzidos à Delegacia. Não soube esclarecer os fatos objeto dos autos, mas afirmou que Richard era usuário.

O réu, interrogado em juízo, sustentou que comprou o entorpecente na cidade de Ibirá e que a droga seria destinada ao seu próprio consumo. Ao chegar na cidade de Urupês, encontrou a pessoa de Richard e, em razão do vínculo de amizade existente entre eles, convidou Richard para ir até a sua residência para usar a droga. Disse que é apenas usuário de drogas e negou a prática do tráfico. Afirmou estar arrependido do consumo de entorpecentes e justificou que pretende se livrar das drogas. Esclareceu que iriam usar uma porção de maconha e, em seguida, levaria Richard até uma "biqueira" onde Richard iria comprar mais drogas. Ratificou que não pretendia vender a droga para Richard.

Ao final da instrução a prova oral colhida é desfavorável ao acusado. Conforme relatado pelos policiais militares ouvidos em juízo, os indivíduos se afastaram ao avistarem a viatura policial. Realizada a abordagem, foram encontradas 06 porções de maconha na posse de Ademir e os indivíduos apresentaram versões contraditórias, sendo que o acusado afirmou que pretendiam consumir o entorpecente em conjunto, enquanto a testemunha Ademir narrou que iria comprar a droga do acusado.

Richard, ouvido em juízo, apresentou versão contrária ao seu depoimento prestado em solo policial. Vale destacar que em solo policial (fl. 05) Richard afirmou que, no momento da abordagem, estavam a caminho da residência de Ademir, pois pretendia comprar cinquenta reais em maconha do acusado e a transação seria concretizada na residência do réu, versão esta coerente com o depoimento prestado pelos policiais

em juízo.

O réu, por sua vez, afirmou ter adquirido o entorpecente na cidade de Ibira, bem como que seria destinado ao próprio consumo. Por outro lado, negou a traficância e justificou que pretendia apenas consumir uma porção de droga na companhia de Richard em razão da amizade existente entre eles.

Logo, não há dúvidas que o réu fora efetivamente surpreendido trazendo consigo 06 porções de maconha, conduta que se amolda ao tipo imputado.

Encontrando-se bem elucidado que a propriedade de todo o entorpecente apreendido realmente deve ser atribuída ao denunciado, o intuito mercantil e, por conseguinte, a traficância, exsurtem evidentes, à luz dos critérios elencados no artigo 28, § 2º, da Lei de Drogas.

Nesse particular, destaco que a diligência policial que culminou com o ajuizamento desta ação penal não se deu ao acaso, decorrendo de inúmeras denúncias alusivas à prática do tráfico pelo acusado, elementos de prova indiciários confirmados pela apreensão de droga na posse do réu.

De se ressaltar que eventual condição de usuário do acusado, por si, não tem o condão de afastar as ilações ora tomadas, eis que as particularidades da ação criminosa e as circunstâncias da prisão justificam a responsabilização pelo crime de tráfico.

Aliás, a rotina forense demonstra que muitos usuários acabam praticando o comércio espúrio para viabilizar a manutenção do próprio consumo, devendo responder pela conduta mais grave, como vem pacificamente entendendo a Egrégia Corte Bandeirante: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP RJTJSP, 101/498);

"Pouco importa, de resto, se o apelante é usuário ou não, pois viciado, quando trafica, deve responder pelo crime mais grave, que se consuma com o mero porte da substância entorpecente, para o fim de entrega a terceiros, independentemente da ocorrência de qualquer ato de comércio." (TJSP - AC 896.821.3/8-00, Rel. René Ricupero J. 30.11.2006).

O fato de não ter sido o increpado flagrado efetuando, propriamente, a comercialização de entorpecente não compromete a materialização do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Como se sabe, o tipo penal em análise constitui delito de ação múltipla ou conteúdo variado, perfazendo-se com a realização de qualquer dos verbos nele descrito, os quais não se encontram submetidos a regime cumulativo.

Atente-se para o quanto já decidido pelos tribunais pátrios:

"Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrario sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente." (RT 584/347).

Na hipótese, consoante já exaustivamente explanado, o acusado trazia consigo grande quantidade de substância ilícita, evidenciando o contexto que o tóxico seria entregue ao consumo de terceiros.

Encerrando a tipificação, com a devida vênia ao entendimento do I. Promotor de Justiça e da D. Defesa, sublinho que a causa de diminuição de pena trazida pelo § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, não se mostra aplicável na espécie. No caso dos autos, verifica-se que o acusado ostenta antecedentes criminais (FA fls. 39/40). Além do mais, a prova oral demonstrou de forma segura e coesa que o réu dedicava-se às atividades criminosas, uma vez que os policiais ouvidos em juízo afirmaram a existência de diversas denúncias indicando a prática do tráfico de drogas pelo denunciado. Assim, não preenchidos os requisitos legais, inviável a redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas no caso dos autos.

Desse modo, apreciadas as teses levantadas por acusação e defesa, não incidindo causa de exclusão da ilicitude ou culpabilidade, impõe-se a procedência dos pedidos formulados, com a condenação do acusado nas sanções contidas no artigo 33, caput,

da Lei 11.343/06

Passo, pois, a dosar a pena, considerando o critério trifásico trazido pelo artigo 68, do Código Penal.

Para fixação da pena-base, devem ser levadas em consideração as circunstâncias judiciais, tanto as genéricas, veiculadas pelo artigo 59, do Código Penal, como as específicas para o delito em análise, insculpidas no artigo 42, da Lei de Tóxicos. Nesse mister, verifica-se que o réu ostenta antecedentes criminais (FA de fls. 39/40). Em que pese o decurso do prazo superior a cinco anos, as condenações definitivas do acusado, cujas penas já foram extintas em razão do cumprimento, serão consideradas como maus antecedentes, de acordo com a tese firmada pelo E. STF no julgamento do RE 591838 no seguinte sentido: "Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal". Desse modo, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa. Não havendo fator a ser considerado na segunda fase da dosimetria, resta aqui inalterada a pena.

Nada há a ser considerado na terceira etapa, valendo registrar que os antecedentes criminais do acusado e a prática do tráfico de forma habitual, conforme demonstrado pela prova oral colhida, afastam a incidência da minorante prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, pois o reconhecimento do privilégio exige, dentre outros requisitos, que o agente não se dedique às atividades criminosas e seja primário.

Inexistindo nos autos elementos que forneçam parâmetros seguros para a aferição da condição econômica do réu, fica o valor do dia-multa fixado no mínimo legal, qual seja, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, nos termos do artigo 43 da Lei 11.343/2006.

Sem confrontar posicionamento recentemente adotado pelo C. STF (habeas corpus nº 97.256/RS, cujos efeitos foram ampliados pela Resolução nº 5/2012, do Senado Federal), diante da existência de circunstância judicial desfavorável e do total da pena aplicada, reputo inviável, na espécie, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ou a substituição condicional da pena, considerada a inteligência dos artigos 44, I e III e 77, caput e II, ambos do Código Penal.

Pelos mesmos motivos, o regime inicial para o cumprimento da pena será o fechado, com fundamento no art. 33, § 3º, do Código Penal.

Destaco, encerrando, que a regra constante da nova redação do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12, não conduzirá à alteração do regime inicial de cumprimento, fixado em função das circunstâncias judiciais especiais desfavoráveis, e não do montante da reprimenda corporal, cumprindo anotar que a regra em testilha não autoriza o juízo do conhecimento a realizar progressão de regime, atribuição exclusiva do juízo das execuções (artigo 66, III, "a", da Lei 7.210/84).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, o fazendo para condenar ADEMIR LUIZ PEREIRA JUNIOR, portador da cédula de identidade R.G. nº 45.001.495/SP, filho de Noeli Perpetua Bastos do Nascimento e Ademir Luiz Pereira, natural de Urupês/SP, devidamente qualificado nos autos (fl. 06), como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, ao cumprimento de pena de cinco anos e dez meses de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

A multa deverá ser paga em dez dias, a contar do trânsito em julgado, nos termos do artigo 50 do Código Penal, observada a disposição constante do artigo 49, § 2º, do mesmo Codex.

Não concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, porquanto, à luz da nova redação dada ao artigo 313, do Código de Processo Penal, pela Lei 12.403/2011, impõe-se a manutenção da prisão, ficando agora reiterados os fundamentos expostos na r. decisão de fls. 74/77, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Ressalto que a prisão preventiva mostra-se como única medida adequada e suficiente para garantia da ordem pública, ou seja, para evitar a reiteração delitiva, ante o envolvimento habitual e reiterado do sentenciado com o comércio de

entorpecentes. Em acréscimo, não se pode ignorar que deverá o sentenciado iniciar o cumprimento de sua pena corporal em regime fechado, de modo que sua libertação nesse momento processual seguramente comprometeria a aplicação da Lei Penal. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra recolhido. Caso haja recurso de qualquer das partes, expeça-se guia de recolhimento provisório, encaminhando-a ao Juízo das Execuções Criminais competente.

Caso tal providência ainda não tenha sido tomada, determino a destruição do entorpecente apreendido, na forma do artigo 50, §§ 3º, 4º e 5º, da Lei 11.343/06. Por fim, restou demonstrado que o valor apreendido (fl. 11) pertencia a Richard Renan Parreira dos Reis e era proveniente de verbas trabalhistas, razão pela qual defiro a restituição do valor apreendido.

Não incidem os efeitos da condenação previstos no artigo 92, do Código Penal, dada a natureza da infração penal praticada.

Deixo de adotar a providência determinada pelo artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, porque o delito praticado não possui vítima certa.

Custas na forma da Lei (artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual 11.608/03), ficando concedido ao réu, patrocinado por causídico indicado pela OAB-SP em decorrência de convênio mantido com a DPE-SP, o benefício da assistência judiciária gratuita.

Anote-se.

Após o trânsito em julgado, proceda-se na forma do artigo 63, § 4º, da Lei 11.343/06, com relação aos bens e valores declarados perdidos em favor da União, oficie-se para suspensão dos direitos políticos do acusado enquanto perdurarem os efeitos da condenação, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal e expeça-se o necessário para o cumprimento definitivo das penas impostas, realizando-se as anotações e comunicações de praxe, tudo de acordo com as NSCGJ (notadamente com os artigos 393 a 400, do capítulo IV, seção XI, subseção V, Tomo I; do artigo 468, do capítulo IV, seção XX, subseção I, Tomo I; e do artigo 479, do capítulo IV, seção X, subseção III, Tomo I).

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários em favor do defensor dativo, no patamar máximo permitido pela tabela pertinente.

Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º das Normas de Serviço da E. Corregedoria Geral de Justiça.

Cumpra-se e Intimem-se.

Urupes, 29 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA